

1502397-36.2021.8.26.0320

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Rogério Danna Chaib

Comarca: Limeira

Foro: Foro de Limeira

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/04/2022

... Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Leonardo Barbosa e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Gabriel Leonardo Barbosa e Pedro Anthony Mathias de Paula, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Limeira

Foro de Limeira

1ª Vara Criminal

Rua Boa Morte, 661, Limeira - SP - cep 13480-181

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502397-36.2021.8.26.0320 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502397-36.2021.8.26.0320

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

Gabriel Leonardo Barbosa e outro

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Rogério Danna Chaib

Vistos.

Gabriel Leonardo Barbosa e Pedro Anthony Mathias de Paula, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06 e ainda com o art. 29, do Código Penal.

Consta da denúncia que na data e local dos fatos, os réus, agindo em concurso e com identidade de propósitos, juntamente com o adolescente L.E.S. C., traziam consigo e tinham em depósito com intuito de tráfico ilícito, trezentas e sete porções da

substância entorpecente denominada Erythroxylon coca (cocaína), em desacordo com determinação legal ou regulamentar.

Sendo oferecida a denúncia, foram os réus regularmente notificados, tendo apresentadas suas defesas prévias, recebendo-se a denúncia com a devida citação dos réus.

Como medida de instrução foram ouvidas testemunhas arroladas pelas partes, também sendo interrogados os réus.

Em alegações finais, a representante do Ministério Público opinou pela procedência da ação por estar demonstrada a autoria e materialidade do delito, tendo a defesa postulado a absolvição dos réus em razão da insuficiência de provas, o afastamento da qualificadora, a desclassificação para a posse de drogas destinada ao próprio consumo, bem como a redução de suas penas, invocando ainda nulidades.

É o relatório.

DECIDO.

Preliminarmente, indefiro a nulidade apontada pela defesa, pelo fato de ter sido descumprido o disposto no art. 212 do Código de Processo Penal, pois a defesa não se insurgiu contra isto no momento adequado e tampouco indicou qual o prejuízo que lhe foi causado.

E este entendimento já foi referendado pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça (AgRg no Recurso Especial nº 1.672.649 - SP -2017/0122646-7, RELATOR: MINISTRO FELIX FISCHER), cabendo enunciar o seu entendimento:

“ Conforme já se verificava na vigência da redação antecedente, o hodierno texto do artigo 212 do CPP continuou a regular apenas o modo de formulação de perguntas pelas partes às testemunhas. Logo, é óbvio que nada mudou no que tange à prerrogativa do magistrado de ser o primeiro a perguntar (matéria não ventilada, no referido artigo, nem antes, nem atualmente, visto que jamais nele se tratou de estabelecer quem indaga inicialmente e quem pergunta depois, ou seja, qual a ordem na inquirição).

[...]

Bem se vê - repita-se - que o artigo em tela, antes e depois, se restringia e se restringe a regular o modo de formulação de perguntas pelas partes. Logo, é totalmente descabido sustentar que a alteração legislativa mudou a posição do Juiz, impondo-lhe que passasse a formular perguntas apenas no final, após as partes, em caráter meramente subsidiário ou secundário.

Aliás, ao contrário, o novo texto procurou, até, reforçar a precedência do magistrado, deixando claro que este (embora seja o primeiro a perguntar), pode voltar a formular indagações no final se as respostas às posteriores perguntas feitas (agora diretamente) pelas partes deixarem pontos obscuros. ”

E a respeito da ordem das perguntas, o festejado Desembargador Guilherme de Souza Nucci, comentando a alteração legislativa do art. 212, do Código de Processo Penal, preleciona:

“ ... tal inovação, entretanto, não altera o sistema inicial de inquirição, vale dizer, quem começa a ouvir a testemunha é o Juiz, como de praxe e agindo como presidente dos trabalhos e da colheita da prova. Nada se alterou nesse sentido. A nova redação dada ao art. 212 manteve o básico. Se, antes, dizia-se ' as perguntas das partes serão requeridas ao Juiz, que as formulará à testemunha', agora se diz que 'as perguntas serão formuladas pelas partes diretamente à testemunha (...) (in Código de Processo Penal Comentado, Ed. RT, 9ª edição, 2009, pg. 483)

Muito embora tenha advindo um julgado de Habeas Corpus (HC 187.035), oriundo do Colendo Supremo Tribunal Federal, concedendo a ordem para anular uma sentença onde, em tese, teria sido descumprido o comando do art. 212 do Código de Processo Penal, trata-se de julgamento isolado da 1ª Turma daquela Corte, o qual ainda não foi sumulado e sequer analisada a questão pelo plenário, para se sustentar sua cogência.

Ademais, no referido julgado há a menção de a autoridade coatora ter induzido respostas e prejudicado o réu, algo que nestes autos efetivamente não ocorreu.

E até mesmo causa espanto a nova interpretação dada por algumas Turmas de Cortes Superiores, quando houve a mudança legal em 2008 e mais de uma década depois, chegou-se ao entendimento de que o Juiz estaria impedido de formular perguntas, como sempre esteve autorizado a fazê-lo, pelo ordenamento jurídico pátrio. Presentes os pressupostos processuais e condições da ação, passo à análise do mérito da questão.

A ação penal é procedente.

Há prova sobre a materialidade do delito, conforme se vê do laudo de exame químico-toxicológico de fls. 181/182 e 184/185 e laudo de constatação de fls. 41/42, constando a apreensão de 41,82 g. de cocaína em pó, divididos em trezentas e sete porções, chamando-se a atenção pelo elevado número de porções e considerável volume, tratando-se de mais de uma espécie de tóxico, revelando ser destinada ao tráfico de drogas.

E ainda houve a apreensão de valores (R\$ 150,00) em poder dos réus, obviamente produto da venda ilícita de drogas (vide fl. 21).

E tendo em vista o conjunto probatório acostado aos autos, perfeitamente possível atribuir aos réus a posse de tóxico destinado ao consumo de terceiros, perfazendo-se a conduta que lhes foi atribuída na denúncia, notadamente pelos depoimentos prestados pelos guardas municipais inquiridos nos autos, tendo eles ainda envolvido um adolescente, em tal prática.

É certo terem os réus negado a prática do delito, apresentando uma versão de que foram ao local dos fatos para comprarem drogas, deparando-se com o adolescente Luiz e outro menor, tendo ali chegado guardas que os prenderam, não chegando a ver onde eles encontraram os tóxicos, alegando Gabriel que possuía apenas um pino de cocaína.

Ocorre que ouvidos os guardas municipais Martins e Nóbrega, relataram ter visto os réus e um adolescente em local onde é rotineira a venda de drogas, estando eles a saírem de uma mata, tendo eles buscado fugir tão logo os viram, mas foram alcançados, tendo o réu Gabriel dispensado vinte e sete porções de cocaína, vindo o adolescente e Pedro indicado onde guardavam mais tóxicos, os quais foram localizados nas imediações, totalizando mais de trezentas porções, tendo eles ainda consigo cento e cinquenta reais oriundos da venda de tóxicos, vindo o adolescente a dizer que apenas atuava como “olheiro” para os réus.

Já o adolescente Luiz Custódio, obviamente escudado em sua inimputabilidade, disse estar no local vendendo drogas e os réus estavam ali para comprar tóxicos, cabendo observar que na fase policial apresentou outra versão, a saber, a de que estava ali para comprar drogas com os réus, negando estar com eles a traficar drogas (vide fl. 16).

Logo, se após uma diligência policial os guardas municipais vieram a abordar os réus, havendo com eles um adolescente, tendo todos procurado fugir, vindo Gabriel a dispensar tóxicos pela via pública e uma vez abordado, confessou o réu Pedro onde guardavam outras porções do mesmo tóxico, ainda tendo eles quantias em dinheiro em seus poderes, obviamente cometeram as condutas a eles atribuídas na denúncia.

O crime em exame é de conteúdo múltiplo, bastando a posse de tóxicos destinado ao consumo de terceiros, não se exigindo a demonstração efetiva da mercancia por parte dos réus.

Inaceitável o argumento de que o réu Pedro não tinha drogas consigo, pois saiu da mesma área verde do que o outro réu e o adolescente, tendo os guardas dito ter sido ele quem indicou onde estavam guardando os tóxicos neste mesmo matagal, sendo estas porções idênticas àquelas que Gabriel portava, sendo indício bastante comprometedor a fuga de todos, quando viram a aproximação dos guardas municipais. E inconcebível a pretendida desclassificação para a posse de drogas destinada ao consumo próprio, quando nem mesmo os acusados afirmaram tal hipótese e isto seria improvável para quem tem em depósito mais de trezentas porções de cocaína.

Evidente ainda a qualificadora contida na denúncia, pois o adolescente foi surpreendido juntamente com os dois réus em local onde era comum o tráfico de drogas, tendo procurado fugir com eles, cabendo ainda enunciar que tal pessoa forneceu mais de uma versão nos autos, revelando incongruência entre elas, pois em verdade, confessou aos guardas municipais estar no local como “olheiro” dos réus. E

se não tivesse tal adolescente envolvimento com os acusados, não buscaria fugir tresloucadamente por uma mata.

Esclareça-se que a despeito das objeções feitas pela defesa a respeito da confissão informal do réu feita aos policiais, isto não se tratou da única prova que lastreia a tese acusatória.

Ao contrário, deve ser enunciado o fato de terem sido os réus detidos em conhecido ponto de venda de drogas, tendo log procurado fugir, dispensando várias porções de cocaína, tendo ainda em seus poderes, o dinheiro apurado com a venda de tóxicos. Inexistiu nulidade quanto a busca pessoal feita, realizada nos moldes do art. 244 do CPP, até porque a Jurisprudência tanto do Colendo Superior Tribunal de Justiça, como do Colendo Supremo Tribunal Federal aponta que eventual irregularidade quanto à informação ao direito de permanecer em silêncio, é causa de nulidade relativa, cujo reconhecimento depende da comprovação do prejuízo (cf. RHC 67.730/PE, Rel. Ministro Jorge Mussi, 5ª Turma, DJE 04/05/2016).

E sem razão a defensoria quando se insurge contra a atividade policial, não havendo qualquer motivo para lhe conferir descrédito, mesmo porque se tratam de funcionários públicos cujos atos gozam de presunção de veracidade e não estão impedidos de depor.

Ademais, seria contraditório o Estado dotar seus agentes de funções preventivas e repressivas à prática criminosas e quando os chama para prestar esclarecimentos sobre seus atos, não conferir crédito às suas versões.

Farta é a Jurisprudência do Colendo Supremo Tribunal Federal nesse sentido, podendo serem extraídos os seguintes julgados:

" O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório, reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal.

O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor, quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando se demonstra - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com outros elementos probatórios idôneos"

(STF -1ª Turma - HC nº 74.608-0/SP - Rel. Min Celso de Mello - DJU 11/04/97, pág. 12.189).

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas ".

(Supremo Tribunal Federal, HABEAS CORPUS Nº 74522 JULGAMENTO: 19/11/1996)

" A prova testemunhal obtida por depoimento de agente policial não se desclassifica tão-só pela sua condição profissional, na suposição de que tende a demonstrar a validade do trabalho realizado; é preciso evidenciar que ele tenha interesse particular na investigação ou, tal como ocorre com as demais testemunhas, que suas declarações não se harmonizem com outras provas idôneas. "

(STF - 2ª T.- HC nº 74.522-9/AC - Rel. Mm. Maurício Corrêa - DJU 13/12/96, pág. 50.167).

Valiosas ainda as lições encontradas em julgado inserto na JTJ 268/525, sendo feita menção a outros acórdãos, encontrados em RJTJSP 13/478 e RT 733/567, no sentido de que ninguém se envolve suasoramente como testemunha processual, tais os encargos e incômodos que assume, quando não fosse o desprazer de contribuir para a responsabilização de outrem. Há uma resistência invencível que leva o homem a esquivar-se e até negar ou calar a verdade. A consciência ética que induz ao dever de colaborar para o cumprimento da Justiça está muito longe de ser atingida.

O agente da segurança é recrutado mediante concurso público para atuar em prevenção e repressão à criminalidade e não é sensato negar-lhe crédito quando, perante o mesmo Estado que o contratou, relata atos de ofício. É compromissado como qualquer outra testemunha e a circunstância de inexistir pessoa não pertencente aos quadros policiais para depor é justificável.

Note-se terem os réus dito que embora conhecessem os guardas municipais antes dos fatos, não tinham qualquer motivo para eles os incriminarem injustamente.

Veja-se a sinceridade do relato dos guardas, tendo eles dito terem visto apenas terem os saído de uma área verde, vindo um deles a dispensar drogas, após a fuga e outro indicou onde guardava o restante do tóxico, com eles havendo um adolescente que alegou ser apenas um "olheiro".

Embora a defensoria alegue ser ilegal a prisão feita pelos guardas municipais, qualquer um do povo pode realizar prisão em flagrante (art. 301 do Código de Processo Penal), ainda mais quando ocorre crime de natureza permanente como o é o tráfico de entorpecentes.

Nesse sentido, o entendimento do Colendo Superior Tribunal de Justiça:

PRISÃO EM FLAGRANTE - Guarda municipal - Apreensão de coisas - Legalidade - Delito permanente.

A guarda municipal, a teor do disposto no parágrafo oitavo, do artigo 144, da CF, tem como tarefa precípua a proteção do patrimônio do município, limitação que não exclui nem retira de seus integrantes a condição de agentes da autoridade, legitimados, dentro do princípio de autodefesa da sociedade, a fazer cessar eventual prática criminosa, prendendo quem se encontra em flagrante delito, como de resto facultado a qualquer do povo pela norma do artigo 301 do CPP. Nestas circunstâncias, se a lei autoriza a prisão em flagrante, evidentemente que faculta - também - a apreensão de coisas, objeto do crime. Apenas o auto de prisão em flagrante e o termo de apreensão serão lavrados pela autoridade policial. Arguição de nulidade rejeitada, visto que os acusados, quando detidos, estavam em situação de flagrância, na prática do crime previsto no artigo 12, da Lei nº 6.368/76 - modalidade guardar substância entorpecente.

(STJ - RHC nº 7.916 - SP - 6ª T - Rel. Min. Fernando Gonçalves - DJU 09.11.98).

Superior Tribunal de Justiça - STJ.

ENTORPECENTE - Tráfico - Guardas municipais que, despidos de mandado judicial, dão voz de prisão e apreendem a droga do portador ou depositário - Admissibilidade por tratar-se de crime de natureza permanente.

(STJ - RO em HC nº 9.142 - SP - 5ª T. - j. 22.02.2000 - rel. Min. José Arnaldo da Fonseca - DJU 20.03.2000).

Ademais, negar a atividade de guardas municipais na prevenção e repressão à prática delituosa seria desconhecer a situação do País que luta de maneira incansável contra o crime e se valem os agentes públicos dos meios disponíveis para prevenir e reprimir principalmente o tráfico de entorpecentes, sustentáculo para diversas outras ações criminosas.

Veja-se que se imaginar uma situação contrária, estaríamos diante de uma situação bastante esdrúxula, ou seja, guardas municipais, armados e em viatura policial, percebem um crime em andamento e vêm a acionar policiais militares ou civis, havendo o sério risco do criminoso fugir e se mostrar infrutífera a diligência policial.

Outrossim, especificamente quanto aos guardas civis, incide a inteligência da Lei n. 13.022/14, que amplia a restrita interpretação que se havia do artigo 144, §8º, da Constituição Federal, dando-lhes, dentre outras competências específicas, as funções de colaboração na apuração penal e na defesa da paz social. Logo, as Guardas Municipais (guardas civis) estão investidas na incumbência da garantia da paz social, atuando na prevenção da prática de crimes, podendo, inclusive, atuar de forma a impedir a sua ocorrência, ou no caso de flagrante, conferir meios para subsidiar a apuração do fato criminoso. Precedentes do STJ (HC 290.371/SP - Rei. Min. Moura Ribeiro - j. 27.05.14; RHC 45.173/SP - Rei. Min. Jorge Mussi - j. 26.05.14 e HC 109.105/SP - Rei. Min. Arnaldo Esteves Lima - j. 23.02.10).

Vale ainda lembrar que no Recurso Especial de nº 1851745-SP, o Colendo Superior Tribunal de Justiça reforçou este entendimento sobre a validade da prisão em flagrante realizada por guardas municipais, versando sobre sentença deste Juízo da 1ª Vara Criminal de Limeira, a qual havia sido anulada pelo E. Tribunal de Justiça de São Paulo.

Assim, comprovada a materialidade do delito e respectivo nexa causal com a autoria delituosa por parte dos réus, impõem-se-lhes o decreto condenatório.

Na dosagem da pena, atento aos critérios norteadores do art. 59 do Código Penal, fixo a pena base dos réus em seu mínimo legal, pois se tratam de réus primários e lhes são favoráveis as circunstâncias judiciais, ficando esta pena base fixada em cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, o unitário no mínimo legal. Esta pena deve ser elevada de um quinto para o réu Gabriel Leonardo, em virtude da circunstância agravante objetiva de ter sido o crime cometido em período de calamidade pública decorrente da pandemia do COVID-19, ficando tal pena elevada para seis anos de reclusão e seiscentos dias-multa.

Já para o réu Pedro, a pena permanece no patamar mínimo, pois a aludida agravante se compensa com sua menoridade relativa.

E diante da qualificadora contida na denúncia, as penas ainda merecem um acréscimo de um sexto, para ficar definitivamente fixada em sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, o unitário no mínimo legal, para o réu Gabriel Leonardo e cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, o unitário no mínimo legal.

O regime inicial para o cumprimento da pena deve ser o fechado, tendo em vistas as recomendações da Lei nº. 8.072/90, já que se trata de delito hediondo.

Vale observar que para a fixação de regime inicial fechado, isto continua a ser estabelecido pelas regras contidas no art. 59 do Código Penal, o qual faz menção ao § 3º, do art. 33, do mesmo Codex, ou seja, não se trata apenas de se analisar a quantidade da pena, mas que este regime inicial atenda à personalidade do acusado e em que circunstâncias cometeu o delito.

Nesse sentido, os seguintes precedentes emanados do Colendo Supremo Tribunal Federal: HC 104.827, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 06/02/2013; HC 111.365, primeira turma, relator o ministro Luiz Fux, DJE de 19/03/2013; are 675.214-agr, segunda turma, relator o ministro Gilmar Mendes, DJE de 25/02/2013; HC 113.880, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 17/12/2012; HC 112.351, segunda turma, relatora a ministra Cármen Lúcia, DJE de 08/11/2012; RHC 114.742, primeira turma, relator o ministro Dias Toffoli, DJE de 08/11/2012; HC 108.390, primeira turma, relatora a ministra Rosa Weber, DJE de 07/11/2012.

Agiam ainda os réus em concurso de agentes, ou seja, em associação criminosa, juntamente com um adolescente, ainda que de maneira não estável, sendo evidente a maior ofensa ao bem jurídico em exame, o que desaconselha a aplicação do redutor de pena previsto no § 4º do art. 33 da Lei nº. 11.343/06.

Veja-se terem sido os réus detidos na posse de cocaína, substância entorpecente que não é produzida neste país e que para aqui chegar, demanda uma verdadeira associação criminosa, da qual os réus fazem parte, sendo o elo final e se há associação criminosa, não há como se conceder o benefício, nos exatos termos da Lei de Tóxicos.

Aliás, tal previsão legal na verdade é absolutamente anacrônica e contrária ao que exige a sociedade brasileira no atual momento.

O tráfico de drogas é o sustentáculo do crime organizado, seja em que nível for e a simples primariedade e bons antecedentes não podem se consistir em verdadeiro escárnio à função preventiva e repressiva da lei penal.

Há quem se refira a um benefício ao chamado traficante de primeira viagem, o que seria salutar, mas no atual momento, onde pessoas são queimadas vivas após um roubo, pais são assinados por filhos e vice-versa, criminosos de dentro de presídios comandam toda a sorte de crimes, indaga-se se o legislador futuramente também não concederá o mesmo benefício a latrocidias, homicidas, estupradores, todos

de “primeira viagem”.

Conhecendo-se a benevolência do legislador penal pátrio, o que vem provocando verdadeira comoção à sociedade indefesa, conceder o referido benefício seria perigosa porta para futuras analogias que somente tem por escopo permitir o retorno ao convívio social de criminosos com personalidade distorcida e que expõem pessoas inocentes ao contato letal com entorpecentes.

Contudo, poderão apelar em liberdade, mantendo-se a atual situação, respeitando-se a decisão exarada em sede de habeas corpus, pela Superior Instância.

Ante o exposto e diante de tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação penal e CONDENO Gabriel Leonardo Barbosa e Pedro Anthony Mathias de Paula, qualificados a fls. 131/133 a pena de sete anos de reclusão e setecentos dias-multa, o unitário no mínimo legal e cinco anos e dez meses de reclusão e quinhentos e oitenta e três dias-multa, o unitário no mínimo legal, respectivamente, sob o regime inicial fechado, dando-os como incursos nas penas do art. 33, caput, combinado com o art. 40, inciso VI, ambos da Lei nº. 11.343/06 e ainda combinado com o art. 61, II, “j”, do Código Penal.

Oportunamente, expeçam-se mandados de prisão em desfavor dos réus.

Custas ex lege, condenando-se os réus, oportunamente, ao pagamento de 100 UFESP, as quais não podem ser cobradas, por ora, sendo eles beneficiários da assistência judiciária.

Com o trânsito em julgado da presente decisão, declare-se a perda em favor da União do dinheiro apreendido em poder dos acusados, nos termos do art. 91, inciso II, alínea “b” do Código Penal.

Publique-se.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Limeira, 19 de abril de 2022.

Rogério Danna Chaib
- Juiz de Direito -

Limeira, 19 de abril de 2022.